

EZRIN HANIZA BINTI HARUN
lwn.
MOHIZAM SHAH BIN DAWOOD SHAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

3 September 2019/3 Muharram 1441H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-026-0089-2018

Peguam Syarie Perayu: Dato' Mohd Zaidi bin Haji Mohd Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Syarie Responden: Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan oleh Perayu terhadap sebahagian keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Mal No. 10000-026-0089-2018 bertarikh 27 Jun 2018. Perkara yang dirayu adalah melibatkan terma keputusan di Perenggan 5, 6 dan 8 seperti berikut:-

- i) *Mahkamah memerintahkan Plaintiff sebagai bapa kandung diberikan hak bermalam dan bersama dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu sebanyak dua (2) kali sebulan bermula pada hari Jumaat jam 7.00 petang dan dipulangkan pada hari Ahad jam 6.00 petang.*

- ii) *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada hari perayaan secara bergilir-gilir setiap tahun antara Plaintiff dan Defendan. Bermula pada tahun 2019 (1440H), Plaintiff akan bersama anak-anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri, manakala Defendan akan bersama dengan anak-anak tersebut pada Hari Raya Aidiladha. Pada tahun 2020(1441H), Defendan akan bersama anak-anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri, manakala Plaintiff akan bersama dengan anak-anak tersebut pada Hari Raya Aidiladha. Begitulah giliran seterusnya dijalankan berselang seli setiap tahun.*
- iii) *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dibenarkan untuk bercuti bersama anak-anak tersebut diluar negara dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada Defendan.*

FAKTA KES

[2] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 8 Mei 2008 dan telah bercerai pada 19 Mac 2015 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak iaitu:-

- 2.1 Elhan Moez Bin Mohizam Shah (No. Mykid: 090903-10-2449);
- 2.2 Iman Madina Binti Mohizam Shah (No. Mykid: 120116-10-1740);
dan
- 2.3 Elia Emira Binti Mohizam Shah (No. Mykid: 140103-10-2048).

[3] Pada 29 Januari 2015, atas persetujuan bersama pihak-pihak, Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes saman no. 10100-028-0018-2015 telah mengeluarkan perintah seperti mana di muka surat 384-385 Rekod Rayuan.

[4] Pada 11 Februari 2016, Responden telah memfailkan permohonan ubah perintah hak jagaan agar terma berkaitan hak lawatan diubah seperti mana yang dituntut dalam Perenggan 9, Pernyataan Tuntutan di muka surat 5 dan 6 Rekod Rayuan.

[5] Pada 27 Jun 2018, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan meluluskan permohonan Responden sepertimana perintah di muka surat 386-388 Rekod Rayuan.

[6] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 9 Julai 2018.

[7] Perayu telah mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan bertarikh 22 Oktober 2018.

[8] Pada 9 Mei 2019, Mahkamah Rayuan Syariah telah membenarkan penyampaian dibuat secara gantian.

Isu

[9] Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membenarkan perubahan perintah sedangkan tiada perubahan matan telah dibuktikan berlaku.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Dalam rayuan ini kami dapati isu yang menjadi pertikaian ialah berkaitan hak akses terhadap anak-anak iaitu hak untuk berjumpa, melawat dan bermalam bersama dengan anak-anak. Hak hadhinah telah dipersetujui diserahkan kepada Perayu.

[11] Asas penghujahan Perayu adalah merujuk kepada ulasan YA Hakim Bicara pada halaman 373 Rekod Rayuan yang menyatakan bahawa:

“ Mahkamah merujuk terma-terma di atas yang dituntut oleh Plaintiff dalam kes ini. Pertamanya Mahkamah merujuk kepada dokumen pengenalan diri anak-anak tersebut iaitu sijil kelahiran yang menunjukkan anak-anak tersebut kini berumur lebih kurang 9 tahun, 6 tahun dan 4 tahun. Maka Mahkamah berpandangan telah berlaku perubahan matan terhadap anak-anak tersebut yang mana pada pandangan Mahkamah anak-anak tersebut kini sudah tidak bergantung kepada penyusuan secara langsung daripada Defendan selaku ibu”

[12] Berdasarkan ulasan tersebut Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila telah menimbulkan isu mengenai perubahan matan anak-anak tersebut sedangkan ianya tidak pernah dibangkitkan oleh Responden dalam Pernyataan Tuntutan atau sepanjang proses perbicaraan.

[13] Sebagai pertimbangan kami telah meneliti Rekod Rayuan yang difailkan pada 14/11/2018. Kami dapati fakta berkaitan anak-anak tersebut dan dokumen pengenalan diri mereka ada dinyatakan di Perenggan 5 Pernyataan Tuntutan.

Fakta ini juga telah menjadi antara fakta yang dipersetujui oleh pihak-pihak sepertimana di halaman 45 Rekod Rayuan.

[14] Kami juga mendapati di halaman 149 Rekod Rayuan, di peringkat soal balas Saksi, Mahkamah ada mengemukakan soalan kepada Saksi 1 Responden (**Harun bin Salim**) yang merupakan datuk sebelah ibu kepada anak-anak tersebut. Saksi menyatakan seperti berikut:

“Soalan Mahkamah :

Anak mereka 3 orang. Yang pertama lelaki, 9 tahun, yang kedua perempuan 6 tahun dan yang ketiga perempuan 4 tahun. Anak yang 4 tahun tidak menyusu badan lagi. Kadang-kadang tiga-tiga minum susu formula”

[15] Berhubung kait dengan soalan Mahkamah ini, kami juga telah meneliti hujah Responden di Mahkamah Tinggi Syariah pada halaman 151-173 Rekod Rayuan. Kami dapati isu perubahan matan berkaitan anak-anak tersebut sudah tidak menyusu badan dan berlaku peningkatan usia telah diujahkan oleh Responden seperti di halaman 165 dan 166 Rekod Rayuan. Sebaliknya, setelah beberapa kali kami meneliti hujah Perayu, di halaman 269-291 Rekod Rayuan, kami tidak menemui adanya hujah Perayu mahupun hujah balas Perayu berkaitan isu yang dibangkitkan oleh Mahkamah tersebut. Ini menunjukkan bahawa isu berkaitan perubahan matan tersebut bukanlah tidak pernah berbangkit di peringkat perbicaraan malahan telah diujahkan oleh Responden dan tidak dijawab oleh Perayu.

[16] Pada hemat kami, berdasarkan keterangan dokumen pengenalan diri anak-anak tersebut dan keterangan Saksi 1 Defendan semasa disoal oleh Mahkamah, sudah mencukupi untuk membuktikan bahawa telah berlaku perubahan matan

sepertimana dapatan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara. Walaupun perintah terdahulu dibuat atas persetujuan bersama tetapi apabila ianya telah dijadikan perintah mahkamah, maka sifat dan kesanya sama sahaja dengan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Perintah persetujuan bersama bukanlah menghalang pihak-pihak daripada memfailkan kes untuk mengubah perintah seperti yang dinyatakan di bawah peruntukan Seksyen 76 Enakmen undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[17] Kami ingin menarik perhatian bahawa hak untuk berjumpa, melawat dan bersama (hak akses) sepatutnya datang bersama-sama (bergandingan) dengan hak jagaan. Sebagai panduan dengan hormatnya kami merujuk kepada ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes ***Nur Nazifa Zafiran Binti Mohd Jami lwn. Zamsari Bin Muhammad, Kes Rayuan No. 10000-028-0046-2016 diputuskan pada 15hb. Mac 2018;***

Disini kami ingin menasihatkan serta memberikan panduan kepada mahkamah bawahan bahawa hak untuk berjumpa, melawat dan bersama (hak akses) sepatutnya datang bersama-sama (bergandingan) dengan hak jagaan. Apabila satu pihak mendapat hak jagaan, maka pihak satu lagi mempunyai hak untuk akses terhadap anak tersebut. Oleh yang demikian, maka perintah berkaitan akses ini sepatutnya diputuskan bersama-sama dengan hak jagaan dan tidak wajar dibicarakan dan diputuskan secara berasingan.

[18] Perayu juga menghujahkan bahawa anak sulong telah mencapai umur mumayyiz, namun YA Hakim Bicara tidak pernah memanggil anak tersebut untuk menyatakan kehendaknya sama ada berkenaan perubahan waktu lawatan, cuti hari

raya dan juga cuti persekolahan. Perayu merujuk kepada peruntukan Seksyen 85 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[19] Kami ingin menyatakan bahawa peruntukan Seksyen 85 tersebut adalah berkaitan hak hadhanah sahaja iaitu kanak-kanak yang telah mumaiyiz berhak memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapanya. Ia bukan berkaitan dengan hak lawatan atau akses. Hak lawatan ke atas anak walaupun anak yang mumayyiz adalah hak bapa dan bukan pilihan anak. Ini bagi membolehkan bapa dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai bapa terhadap anaknya. Perkara ini adalah berdasarkan rujukan terhadap tulisan Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 7, Dar al-Fikr, Damsyiq, Cet. 4, hal. 7321 menyebutkan:

والحنابلة كالشافعية قالوا : ان اختار المميز أباه كان عنده ليلا و نهارا , ولا يمنع من زيارة أمه , ولا تمنع هي من تمريره . وان اختار ها كان عندها ليلا , وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه .

Maksudnya: “Mengikut pendapat mazhab Hanbali dan juga mazhab al-Syafie: sekiranya anak yang mumayyiz memilih bapanya, maka ia bersama bapanya siang dan malam, dan bapa tidak boleh melarangnya bagi menziarahi ibunya, dan juga bapanya tidak boleh melarang ibunya merawat anak itu bila anak itu sakit. Sekiranya anak itu memilih ibunya, maka anak itu bersama ibunya pada waktu malam dan bersama bapanya pada waktu siang supaya bapa dapat mendidiknya dan mengajarkannya.”

[20] Akhir sekali berdasarkan penelitian kami terhadap alasan rayuan dan hujah yang dikemukakan oleh Perayu, kami tidak menemui adanya asas-asas yang boleh

diberi pertimbangan dari segi Hukum Syarak untuk kami menghalang Responden sebagai bapa kepada anak-anak tersebut untuk melawat dan bermalam bersama dengan anak-anaknya. Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara yang mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam perintah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah Perayu, maka kami SEBULAT SUARA memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor